

1501127-74.2022.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Glaucio Roberto Brittes de Araujo

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... se prolonga no tempo), como é o caso de tráfico de entorpecentes, na modalidade 'ter em depósito' ou 'trazer consigo', pode o policial penetrar no domicílio efetuando a prisão cabível" (Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., São Paulo: RT, 2012, p. 569).

E a jurisprudência não destoa:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRELIMINARES - Recurso em liberdade. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

4ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501127-74.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501127-74.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2115403/2022 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 24608589 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS, 2115403 - DISE- DEL.SEC.GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

WILLIAN JUNIOR BARBOSA DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Glaucio Roberto Brittes de Araujo

VISTOS.

WILLIAN JUNIOR BARBOSA DE OLIVEIRA, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, dia 28 de abril de 2022, por volta das 12h50, na Rua Carmen Miranda, altura do nº 400, Bairro Jardim Bananal, nesta cidade e comarca de Guarulhos, trazia consigo, para fins de tráfico, 690 eppendorfs contendo 555,45g de cocaína, 151 porções contendo 291,92g de Cannabis Sativa L, droga vulgarmente conhecida por "maconha" e 30 frascos contendo quantidade ainda incerta da substância Tricloroetileno, vulgarmente conhecida como "lança-perfume", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 10, laudo de constatação provisória a fls. 19/23 e exame químico-toxicológico a fls. 53/55.

A denúncia foi oferecida (fls. 65/69), o réu foi notificado e apresentou resposta à acusação (fls. 78/83). A denúncia foi recebida e, não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 98/100).

Em instrução regular, foram ouvidas três testemunhas comuns à acusação e defesa e o acusado foi interrogado.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia. No tocante à dosimetria, requereu o aumento da pena, na primeira fase, tendo em vista a quantidade de droga. Bateu-se pelo regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, preliminarmente, invocou a nulidade processual por invasão de domicílio. No mérito, postulou absolvição do acusado nos termos do artigo 386, I, V, VII, do CPP. Requereu, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da lei de drogas. No que toca à dosimetria, insistiu na aplicação da pena no mínimo legal e do privilégio. Bateu-se pelo regime inicial aberto e pelo direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, não há que se falar em nulidade pela suposta invasão de domicílio.

No caso em apreço, o acusado já havia sido detido em flagrante delito na posse dos entorpecentes. Os policiais apenas foram até sua casa para eventual apreensão de mais drogas, produtos e instrumentos do mesmo crime. Não se comprovou cabalmente, ademais, a negativa de ingresso por qualquer morador na residência. Por fim, a apreensão em poder do réu já configurava evidência suficiente da guarda de mais droga no imóvel, justificando a diligência. Desta feita, o estado de flagrante delito configura-se como exceção à inviolabilidade do domicílio, sendo este também o sólido entendimento doutrinário e jurisprudencial. Transcreve-se lição de Guilherme de Souza Nucci:

"Desnecessidade de mandado em caso de flagrante: é indiscutível que a ocorrência de um delito no interior do domicílio autoriza a sua invasão, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem o mandado, o que, aliás, não teria mesmo sentido exigir fosse expedido. Assim, a polícia pode ingressar em casa alheia para intervir num flagrante delito, prendendo o agente e buscando salvar, quando for o caso, a

vítima. Em caso de crimes permanentes (aqueles cuja consumação se prolonga no tempo), como é o caso de tráfico de entorpecentes, na modalidade 'ter em depósito' ou 'trazer consigo', pode o policial penetrar no domicílio efetuando a prisão cabível" (Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., São Paulo: RT, 2012, p. 569).

E a jurisprudência não destoa:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRELIMINARES - Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Superveniência de pedido de prisão domiciliar (Recomendação nº 62/2020 do CNJ). Constrangimento ilegal não detectado. Pleito não levado ao juízo de primeiro grau competente. Supressão de instância - Nulidade. Invasão de domicílio. Crime permanente e estado de flagrância - Rejeição. MÉRITO - Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelo depoimento do policial militar e da testemunha, tudo em harmonia com o conjunto probatório - Apreensão de razoável quantidade e variedade de entorpecentes (137 porções de 'cocaína', com peso líquido de 114,28 gramas; e 07 porções de 'maconha', com massa de 25,99 gramas), além de dinheiro e telefone celular - Desclassificação para uso próprio. Impossibilidade - Condenação mantida. PENAS E REGIME PRISIONAL - Bases acima dos mínimos (1/5) - Quantidade e variedade de drogas. Readequação do coeficiente para 1/6. Proporcionalidade - Multirreincidência e confissão espontânea. Compensação da atenuante com uma condenação. Utilização da condenação remanescente para manter o aumento das penas em 1/6 - Inviável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Regime inicial fechado - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) - Perdimento dos valores e objeto apreendidos em favor da União - Apelo provido em parte para reduzir as penas." (TJSP; Apelação Criminal 1502606-32.2019.8.26.0269; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Porangaba - Vara Única; Data do Julgamento: 29/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020).

No mérito, a ação penal procede.

A materialidade e autoria restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10), laudo de constatação (19/23), laudo de objeto (fls. 111/114), laudos de exame químico-toxicológico (fls. 115/117 e 118/120) e prova oral colhida em Juízo.

A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas, as circunstâncias da posse, a quantia de R\$ 35,00, os três aparelhos de telefone celular apreendidos e demais informações dos policiais evidenciam que o entorpecente seria fornecido a terceiros. A conduta corresponde, perfeitamente, ao tipo penal do art. 33, da Lei 11.343/06.

O réu negou vagamente a prática de delitiva, alegando que foi ao ponto de venda com vinte reais para comprar maconha e, quando era atendido por um rapaz, um policial moreno chegou. O primeiro passou a fazer perguntas para este e pediu que mostrasse a cintura, a fim de verificar se não estava armado. Em seguida, saiu correndo e abandonou os entorpecentes. Aduziu que os policiais Manuel e Ricardo chegaram e, então, fizeram a sua prisão. Manuel chegou a indagá-lo se não assumiria o BO, bastando informar que a droga vinha de Nazaré. Seguiram para a sua residência e lá ingressaram sem sua autorização, mas nada encontraram. Afirmou que não os conhecia e que nada disse no DP, embora qualquer inocente nessa situação certamente apresentaria justificativa ou narrativa do ocorrido. Admitiu que não conhecia o escrivão e o delegado, nada tendo contra eles. Não soube dizer por que o incriminam e esse suposto terceiro policial jamais foi encontrado e indicado para ser ouvido. A versão confusa, vaga, isolada e inverossímil acabou refutada pelas provas colhidas.

O policial Ricardo afirmou que, em conhecido ponto de tráfico, avistaram o réu aparentemente fazendo uma venda. O suposto usuário se distanciou e abordaram o acusado, que estava na posse de uma mochila, onde localizaram várias porções de drogas, incluindo maconha, lança-perfume e cocaína. Destacou que ele prontamente confessou que estava há algum tempo no tráfico e ganhava R\$180,00 a R\$ 200,00 (cento e oitenta a duzentos reais) por dia. Respondeu à defesa que estiveram na casa do réu com sua autorização e após o flagrante, como de rotina, para buscar seu documento e fizeram a revista no local, onde nada foi encontrado. Não o conhecia. Declarou que ficou com o réu, enquanto seu parceiro de trabalho Manuel ingressou na residência.

A testemunha Manuel afirmou que fizeram a campana a 50m (cinquenta metros), aproximadamente, e que viu o réu fazer aparentemente uma venda de drogas em conhecido ponto de tráfico, motivo pelo qual o abordaram, apreendendo em seu poder uma mochila com várias porções de drogas variadas, dinheiro e aparelhos celulares. Não se recordou se eles estavam funcionando e se o suposto usuário era parecido com o acusado. Destacou que estiveram de fato na residência do réu, com a sua autorização e sem mandado, onde ingressou para a busca, mas nada de ilícito encontrou. Confirmou que o réu não entrou na residência durante a busca. Acrescentou que o réu confessou informalmente que estava no tráfico e ganhava R \$200,00 (duzentos reais), aproximadamente, por dia

A testemunha Alice afirmou que foi procurada pelos policiais que estavam com o réu já detido. Eles a orientaram a avisar a família que ele estava sendo preso e não o viu dentro do imóvel. Respondeu que viu apenas o policial ingressar e que a chave ficou na porta da casa. Não soube informar mais nenhum detalhe sobre a prisão e o flagrante anterior do réu, tendo apenas corroborado as informações dos próprios policiais. Confirmou que ele é usuário, o que não afasta a possibilidade, por si só, de se dedicar também ao tráfico.

Como se percebe, os fatos narrados na exordial acusatória restaram devidamente comprovados. No dia referido, o acusado estava em via pública realizando a traficância. Entretanto, policiais notaram a venda de droga para um usuário e efetuaram a abordagem. Submetido à revista pessoal, na mochila que estava na posse do réu, os policiais localizaram substâncias entorpecentes, além da quantia, em espécie, de R\$ 35,00 e mais três aparelhos de telefone celular. O réu foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia, onde novamente confessou a prática do crime, acrescentando que estava na atividade ilícita há seis meses e recebia, para tanto, a quantia de R\$ 200,00 por dia (fls. 06).

No caso em apreço, os testemunhos atestaram, em uníssono, com detalhes, coerência e firmeza, a posse das drogas pelo réu, em quantidade e diversidade incompatíveis com uso próprio, enquanto a defesa não soube relatar dinâmica diversa convincente e não cogitou de motivo para ser supostamente incriminado falsamente. Todos esses fatores refutam, substancialmente, a versão judicial ulterior de que não estava traficando, mas buscando entorpecente para seu uso. Não se alegou e não se demonstrou, outrossim, que a grande quantidade e diversidade de drogas pertencia a terceiros, sequer visualizado no local, ou que se destinaria apenas ao uso pessoal.

Não obstante os argumentos da Defesa, a narrativa de que foi abordado por um terceiro policial desconhecido e de que, em conluio com os depoentes, forjou o flagrante, deixando o traficante fugir, ao invés de persegui-lo, é desprovida de sentido lógico e suporte indiciário mínimo. Contrasta, ademais, com a confissão inicial, testemunhos e todos elementos dos autos. A retratação previsível, como sói acontecer, não foi sequer corroborada por sua testemunha, assim como as conjecturas sobre o ingresso posterior da polícia no seu domicílio. A propósito, os próprios policiais justificaram a contento a diligência e reconheceram que nada mais de interesse foi apreendido.

Portanto, cabalmente demonstrada a posse de porções prontas para venda e relatada a realização de uma antes da abordagem, as evidências do dolo são fartas. Absurda ainda a ideia de que policiais prestariam falsos testemunhos, sobretudo acerca de sua reação sintomática, visibilidade do ato de traficância e confissão em sede policial, para incriminarem um desconhecido inocente, submetendo-se ao risco de responsabilização funcional e criminal, sem nenhuma perspectiva de vantagem.

Além disso, não há razão concreta para desprezar as declarações de testemunhas sob compromisso formal, inclusive acerca das evidências robustas e convergentes do dolo. Saliente-se que merecem crédito e são dotados de valor probatório determinante, em delitos de tal jaez. Nesse sentido, há farta jurisprudência:

“O valor de depoimento testemunhal de policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF, HC nº 73.518-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.1996).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM TESTEMUNHOS PRESTADOS POR POLICIAIS. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. (...) 2. Não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese, em que a expressiva quantidade de droga apreendida - 24 (vinte e quatro) invólucros com crack - revela não ser o entorpecente destinado a consumo próprio. 3. Tem-se por adequado o regime fechado para o início do cumprimento da pena corporal de 5 (cinco) anos aplicada ao paciente pelo tráfico de drogas, dado o estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal em conta do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas, não se olvidando a quantidade de entorpecente que trazia consigo. 4. Ordem denegada.” (STJ, HC n.º 223086 / SP; 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.11.2013).

E o decreto condenatório não se baseia tão somente nos dados do inquérito ou palavra de policial. No caso concreto, todos os elementos probatórios harmonizam-se, inclusive aqueles obtidos na fase judicial, sendo certo que o magistrado pode utilizar todos na formação de seu convencimento. Ainda que assim não fosse, não há óbice à valoração, embora relativa, dos elementos colhidos na fase de investigação para fundamentar eventual decreto condenatório, porquanto a vedação legal é no sentido da impossibilidade de condenação lastreada exclusivamente em tais provas, nos exatos termos do art. 155 do CPP. Neste sentido, é a jurisprudência:

“(...) Mostra-se válida a condenação imposta com auxílio de dados obtidos na fase inquisitorial se tais estão em consonância com o apurado em juízo. O desprezo ao que se produziu na fase investigativa não é possível por força do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, adotado em nosso ordenamento. Portanto, ainda que tenha a princípio menor valor o elemento produzido no caderno inquisitivo, por força do disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, não pode tal ser afastado de pronto. No caso dos autos a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, confirma e corrobora a prova produzida tão somente no inquérito policial. Assim a prova deve ser vista como um todo, não se considerando o lugar onde foi produzida, mas o valor probante, estando garantido os direitos constitucionais do réu, conforme acima exposto”. (TJ/SP, Apelação nº 0039765-66.2010.8.26.0506, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Lauro Mens de

Mello, j. 28/04/2016).

Neste diapasão, os relatos dos policiais foram coerentes nas duas fases processuais, minuciosos, harmônicos, seguros e condizentes com os elementos sensíveis da infração. Não havia motivos, a propósito, para incriminarem falsamente um desconhecido inocente. Também não sugeriram indícios de que a droga pertencesse a outrem, de mácula ou de equívoco no flagrante.

No mais, em delitos de tal natureza, as evidências são determinantes para elucidação do vínculo subjetivo entre o agente, o dinheiro e as drogas e de sua destinação, sendo inviável prova concreta e cabal do seu pensamento. De outro lado, não se alegou pronta e espontaneamente e não ficou evidenciado que toda aquela droga variada apreendida seria consumida, em via pública, algo inviável humanamente. Destarte, não há que se falar em desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas.

De qualquer sorte, a quantidade, a variedade e forma de acondicionamento das drogas e as circunstâncias da ação e confissão inicial revelaram sobejamente a destinação a terceiros. O acusado é imputável e praticou os atos típicos descritos na norma penal. Justificativas relativas à situação econômica ou vício, ainda que, em tese, tivessem contribuído para a traficância, não são dirimentes da ilicitude ou da culpabilidade. Não justificam a despicienda ofensa ao bem jurídico.

Finalmente, nenhum álibi restou comprovado de maneira inequívoca e nenhuma excludente ficou configurada. Não pairam dúvidas sobre o liame subjetivo entre o réu e a droga encontrada e sobre a finalidade de fornecimento a outrem.

Portanto, comprovada a materialidade delitiva e evidenciada a autoria, ante o complexo probatório robusto e coerente produzido nos autos, impende apreciar a dosimetria da pena fixando-a no patamar suficiente e necessário à reprovação do delito.

Bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, consistente em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, considerando a primariedade (fls. 25/26). A variedade e quantidade não destoam do normal em empreitadas desse jaez, sendo determinante na configuração do próprio tipo penal. Saliento que a quantidade e variedade serão avaliadas na terceira fase para redução menor da pena.

Na segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira etapa, em razão da primariedade e falta de provas de que o réu integra organização criminosa ou se dedica permanentemente à atividade criminosa, incide a redução postulada a título de tráfico privilegiado. Não é absolutamente certo que, por ocasião do flagrante, já vinha realizando a atividade de maneira duradoura. Nenhuma testemunha se pronunciou sobre esse fato. Não foram encetadas diligências para apurar a hipótese de efetiva dedicação e não de pontual ou isolado ato de venda. Da quantidade ou variedade apenas e até mesmo da mera confiança de que traficava há algum tempo, sem orientação sobre o direito ao silêncio e as formalidades legais, não se extrai com absoluta certeza o vínculo duradouro, atual e sólido com a criminalidade, à luz da correta exegese da expressão “dedicação”. Assim, na falta de tais elementos e de condenação anterior, urge conceder oportunidade para o iniciante de ressocialização em condições menos gravosas para sua liberdade.

Considerando, por outro lado, a grande quantidade e diversidade de drogas, além da ausência de arrependimento revelado em confissão, a reprimenda é reduzida no patamar de apenas 1/6, totalizando 4 anos e 2 meses de reclusão, além de 416 dias-multa. Não se nega o benefício, mas deve se coadunar com as peculiaridades do caso.

À míngua de critérios seguros e explicitamente estabelecidos para a aplicação do art. 33, par. 4, da Lei 11343/06, o art. 42 do referido diploma legal deve orientar o patamar daquela redução. Restringir este preceito à fase do art. 59, do Código Penal, a par de despiciendo, criaria distinção injustificada em relação a outros delitos, na primeira etapa de dosimetria da pena, e não permitiria solução eficaz para a controvérsia acerca dos critérios de redução da terceira fase. Por conseguinte, no caso em apreço, ante a quantidade e natureza da droga, somente cabe a redução mínima, estando preservado o prudente arbítrio do julgador.

A propósito, a lei estabelece somente que as penas “poderão” ser reduzidas. Além disso, entende-se que por se tratar de causa de redução - que pode ir aquém do mínimo legal - e não de dosimetria da primeira fase, não se adota a pena menor em perspectiva (diminuição máxima) como regra. Muito pelo contrário, a legislação recente destinou-se ao agravamento da coibição, da repressão e da resposta penal para o tráfico de entorpecentes, sendo ilógica e dissociada do princípio da razoabilidade a exigência peremptória da diminuição máxima da pena, que a levaria a um patamar muito inferior ao da lei antiga.

Segundo exegese sistemática e teleológica, o percentual de diminuição deve ser escolhido de acordo com o caso concreto, o grau de culpabilidade e especificidade do potencial lesivo da conduta, como possível número de usuários em perspectiva e danos à saúde destes. Assim, nega-se a diminuição máxima. Não havendo mais causas de diminuição ou de aumento, a reprimenda permanece no patamar anteriormente fixado.

Assim, tendo em vista o “privilégio”, as circunstâncias favoráveis do artigo 59, do CP, e a natureza do crime (sem violência ou grave ameaça), que dispensam o regime fechado, mas atento à quantidade da pena (superior a 4), fixo o regime inicial semiaberto. Por se tratar de tráfico de drogas privilegiado, cumpre observar decisões recentes dos Tribunais Superiores no sentido de que o referido crime não é hediondo e enseja regime compatível com a quantidade da pena. A despeito da possibilidade, em tese, de regime mais gravoso em razão de fatores específicos, como a grande quantidade de drogas, no caso em apreço não realizou atos próprios de posição relevante no tráfico e não conta com anotações criminais. Possível, assim, concessão de primeira e única oportunidade para prevenção e ressocialização em regime mais brando, correspondente por lei ao quantum da pena. Sobre a temática, confira-se:

“EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDIVIDUAL E COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DIRETRIZES REGISTRADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641 (PLENO). PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006). TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO. CONSECTÁRIOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA NORMATIVA. ESTUDO DO INSTITUTO CONECTAS E DADOS ESTATÍSTICOS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO TRIBUNAL IMPUGNADO. DESRESPEITO AO SISTEMA DE PRECEDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE. ISONOMIA DO JURISDICIONADO. BUSCA À RACIONALIDADE PUNITIVA. PREDICATIVO ÍNSITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE”. (STJ, HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1) - Decisão Monocrática- Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).

“EMENTA PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso que espera a absolvição. Impossibilidade. Provas dos autos que evidenciam a autoria e materialidade delitivas de forma robusta. Confissão judicial e palavras dos PMs. Condenação mantida. Possibilidade de redução das penas. Ausência de indicativos de dedicação ao crime. Privilégio aplicável aos réus, primários. Redutor na fração de um quinto,

considerada a quantidade de entorpecente apreendida. Regime inicial intermediário suficiente para a reprovabilidade do delito. Apelos providos em parte para redução das penas. (TJ/SP, Apelação n.º 0001273-25.2018.8.26.0635; 16ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, j. 19/08/2020).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. PACIENTE RAFAEL. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. UTILIZAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E PARA A NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ANÁLISE PREJUDICADA. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO, DE OFÍCIO" (STJ, Habeas Corpus nº 317.461-SP, Sexta Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 26.05.2015).

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. VERIFICAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. 10 KG DE COCAÍNA. SUPOSTA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DO DECISUM A QUO. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA ORIGEM. 1. Na dosimetria do delito de tráfico de drogas, configura bis in idem utilizar a gravidade e quantidade da droga apreendida para, a um só tempo, fixar a pena-base acima do mínimo legal e afastar a aplicação da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 2(...)" (STJ, AgRg no Recurso Especial nº 1.491.994-GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19.05.2015).

Ademais, tal conclusão também decorre da Lei de Execuções Penais, com as alterações trazidas pelo pacote anticrime (Lei n.º 13.964/2019), mais precisamente da redação art. 112, § 5º da LEP: "Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006."

Com todo respeito ao inconformismo e razões invocadas pelo MP, suposto descabimento da via eleita para pretensa prevenção de interesse coletivo contra legítimo entendimento predominante no TJSP e concepção conferida à proporcionalidade não são suscetíveis de reavaliação pelo juízo de primeiro grau, sendo contraproducente, ademais, a prolação de decisão em sentido oposto à orientação dos tribunais superiores, que desafiaria recursos e eventual reclamação em detrimento do resultado profícuo do processo e da economia processual.

Em contrapartida, a despeito da compreensível necessidade de algum tempo para outorga da prestação jurisdicional de primeira instância, não é possível conceber regime diverso, mediante estimativa da detração e prognóstico de progressão. Além de destoar dos fundamentos da pena, a aplicação de regime aberto, sem correspondência com a disciplina legal da dosimetria, mas com base na duração da custódia provisória, exígua aliás, é desprovida de prova cabal dos requisitos. Não é certo que o período de custódia já autorizaria detração e progressão, na falta de cálculo e de atestado de comportamento carcerários. Ademais, ausentes elementos, inclusive para avaliar condições subjetivas, a aplicação de outro regime não atenderia aos princípios da individualização da pena e da medida da culpabilidade, restando a análise do mérito da alteração de regime em breve mediante execução provisória.

Finalmente, superando-se quatro anos de pena e não sendo socialmente recomendável, sobretudo pela grande quantidade e diversidade descabe no caso concreto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista na Lei n. 9714/98, assim como o sursis.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a

pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o acusado WILLIAN JUNIOR BARBOSA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, no cumprimento da pena privativa de liberdade de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 416 dias-multa, no valor unitário mínimo, com atualização monetária, como incurso no artigo 33, cc par. 4, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu não poderá recorrer desta sentença em liberdade, já que permaneceu preso até a presente decisão, sendo contraproducente sua soltura, neste lanço, em detrimento da aplicação da lei penal, após imposição de regime não aberto. Ademais, a gravidade do delito, sobretudo a quantidade e diversidade de droga apreendida, que coloca em risco o meio social e fomenta outros crimes, torna necessária a custódia como garantia da ordem pública. De qualquer modo, a execução provisória imediata não causará prejuízos ao acusado, que terá eventuais benefícios analisados com os dados necessários e cálculo exato. Recomende-se o acusado no ergástulo onde se encontra. Expeça-se guia de recolhimento, oportunamente.

Transitada esta em julgado, far-se-á a necessária comunicação ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para o fim previsto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido e celulares, ante as evidências da relação com o tráfico, e determino a incineração da droga apreendida.

Custas e despesas processuais pelo réu pelo sentenciado, respeitada a gratuidade.

P.I.C.

Guarulhos, 03 de agosto de 2022.

GLÁUCIO ROBERTO BRITTES DE ARAUJO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA